

1500814-13.2020.8.26.0106

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... probatória quanto ao crime de roubo. O fato de o réu ter sido apreendido com o veículo roubado não é prova suficiente de que ele participou do crime de roubo.

Requer a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de receptação.

Quanto a dosimetria, pugna pela pena base em seu mínimo legal.

Documentos juntados: Boletim de ocorrência (fls. ...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500814-13.2020.8.26.0106 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500814-13.2020.8.26.0106

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2265240/2020 - DEL.POL.CAIEIRAS, 14332318 - DEL.POL.CAIEIRAS,

1853/20/202 - DEL.POL.CAIEIRAS, 2265240 - DEL.POL.CAIEIRAS, 2265240 -

DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 1853/20/202 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Averiguado e Réu:

JOSE DA SILVADOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

LEONARDO LEITE DA SILVA qualificado às fls. 15, e WESLLEY BRYAN SILVA MOURA qualificado às fls. 16, estão sendo processados como incurso nos artigos artigo 157, §2º, incisos II, §2º-A, inciso I, e artigo 330, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "b", ambos na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, porque segundo narra a denúncia de fls. 106/108, no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 20h30min, na Rua Virgílio Martins de Oliveira, nº 250, Jardim Professor Morato, cidade e comarca de Francisco Morato, agindo em concurso e com identidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 1 (um) aparelho celular, marca Iphone SE, IMEI 35922207380812, e 1

(um) veículo VW/Gol, placa FEK6C75, pertencentes à vítima Jeferson Vieira da Silva. Consta, também, que no dia 23 de outubro de 2020, em horário incerto, na altura do KM 30 da Rodovia SP 332, cidade e comarca de Caieiras, os acusados desobedeceram a ordem legal de funcionários públicos, consistente em ordem de parada emanada pelos policiais militares Denilson Souza dos Santos e Fabio Vitor da Silva, a fim de assegurar a impunidade e a vantagem do crime anterior. O representante o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos acusados (fls. 97/105)

A decisão de fls. 117/118 recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos corréus, bem como determinou a citação de ambos.

Wesley Bryan Silva Moura foi preso em 23 de julho de 2021 (fls. 154/157) e Leonardo Leite da Silva em 02 de agosto de 2021 (fls. 158/161). Leonardo foi citado (fls. 163) e apresentou resposta à acusação às fls. 185. O réu Wesley Bryan Silva Mora foi citado (fls. 165) e apresentou resposta à acusação às fls. 170.

A decisão de fls. 196/197 ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e debates por videoconferência em razão da Pandemia da Covid-19. Em audiência foi ouvida a vítima, as testemunhas, bem como os réus foram interrogados.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Para ambos os acusados, bem como para ambas as infrações penais, na primeira fase de dosimetria da pena, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, haja vista o expressivo valor econômico subtraído da vítima (um aparelho celular e um veículo), bem como por ser o réu LEONARDO portador de maus antecedentes. Na segunda fase pugna pela agravante do artigo 61, incisos I e II, alínea "b", uma vez que delito de desobediência foi praticado com o intuito de assegurar a impunidade e a vantagem do roubo, bem como em razão da reincidência do réu Leonardo. Na terceira fase requer o reconhecimento das agravantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Pugna pelo regime inicial fechado (fls. 225/232).

A defesa de Wesley Bryan Silva Moura apresentou alegações às fls. 233/238 pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requer o afastamento da agravante do uso de arma de fogo, tendo em vista que a arma não foi apreendida e periciada para comprovar se a arma era verdadeira e com potencial lesivo à integridade física da vítima, bem como a vítima em seu depoimento não esclareceu quanto ao objeto que foi utilizado pelo réu Leonardo para exercer a ameaça. Quanto ao crime de desobediência, pleiteia pela absolvição uma vez que não era o corréu Wesley quem conduzia o veículo, sendo certo que a ordem de parada só podia ser obedecida por quem estava dirigindo o veículo. Requer ainda o afastamento da causa de aumento do artigo 61, II, "b" do Código Penal. Para a aplicação da pena, observar que o réu é primário e de bons antecedentes, fazendo jus a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, superando a Súmula 231 do STJ em virtude do princípio da individualização da pena.

A defesa de Leonardo Leite da Silva apresentou alegações finais às fls. 239/249, pugnando preliminarmente a nulidade do reconhecimento na fase policial. No mérito, sustenta insuficiência probatória quanto ao crime de roubo. O fato de o réu ter sido apreendido com o veículo roubado não é prova suficiente de que ele participou do crime de roubo. Requer a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de receptação. Quanto a dosimetria, pugna pela pena base em seu mínimo legal.

Documentos juntados: Boletim de ocorrência (fls. 05/07); Auto de Exibição e apreensão (fls. 09/10); Folhas de antecedentes (fls. 110/113 e 114/116) e Certidão de distribuição criminal (fls. 141/143 e 144/145).

É o relatório.
Fundamento e decido.

PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Sustentou o corréu Wesley Bryan Silva Moura a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, vez que não observado o procedimento legal, sendo que referido reconhecimento deve ser considerado nulo. O corréu Leonardo Leite da Silva também pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico, sustentando que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

De fato, observando-se os documentos acostados às fls. 08 e 41, verifico divergências quanto a afirmação da vítima em juízo, que afirmou ter reconhecido os corréus em solo policial por fotografias.

No entanto, primeiramente, cumpre-nos destacar, que eventual decreto condenatório não precisa estar estritamente relacionado com o ato viciado, ante o princípio do livre convencimento do juiz. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FORMAL VICIADO. AUTORIA DELITIVA CONSTATADA POR OUTRAS PROVAS SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ATO VICIADO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.886/SC. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento" (HC 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso em análise, embora o reconhecimento pessoal do acusado não tenha seguido as formalidades do art. 226 do CPP, o Juízo processante se convenceu da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardaram relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento, tendo registrado na sentença que: "A autoria, por sua vez, também é irrefutável, na medida em que o réu foi prontamente reconhecido pela vítima Oscarino, conforme auto de reconhecimento pessoal de fls. 09, bem como pelas demais provas produzidas nestes autos.". No ponto, destaca-se o depoimento da vítima Emília que afirmou que "seu marido reconheceu Marcelo como um dos assaltantes, pois ele frequentava a sua casa", sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos na via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 644656 SP 2021/0040054-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Sobre o tema, ressalto ainda recente decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 598.886/SC, onde foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

Nesta esteira, considerando que, de fato, há aparentes irregularidades no auto de reconhecimento de fls. 08 e 41, quando corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, determino que seja oficiada a corregedoria da polícia civil, com cópias dos respectivos documentos e oitiva da vítima, para as providências que entender pertinentes.

No mérito a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A denúncia preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto que, ausentes hipóteses legais de rejeição previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal. Assim, não demonstrada de pronto nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal de absolvição sumária, na medida em que não há prova nos autos da existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato, da culpabilidade do réu, nem tampouco provas de que o fato não constitui crime ou de que está extinta a punibilidade do acusado), foi confirmado o recebimento da denúncia às fls. 196/197.

Tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos bem como pelos depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo.

A vítima JEFERSON VIERIA DA SILVA na delegacia (fls. 11) afirmou "declaro que trabalho como motorista de aplicativo 99, de modo que, no dia 21.10.2020,, por volta das 20h30, ao estacionar meu automóvel, uma VW Gol, placas FEK6C75, na Rua Virgílio Martins de Oliveira, altura do número 250, na Cidade de Francisco Morato-SP, fui abordado pelos dois homens que no momento sei se chamarem Leonardo Leite da Silva e Wesley Bryan Silva Moura, tendo eles anunciado o roubo. O homem que no momento reconheço como Leonardo estava armado com um revólver prateado e eles roubaram de mim meu aparelho de telefonia celular,, um Iphone SE IMEI 359222073808120 e também meu carro, um VW Gol de placas FEK6C75, e em seguida se evadiram sentido CSU, bairro santo Antonio Expedida MSG. Em razão dos fatos registrei o boletim de ocorrência n.2858/20, na Delegacia de Francisco Morato e hoje fui contatado a comparecer nesta delegacia, haja vista a localização do meu veículo e a captura dos responsáveis, o quais reconheço sem a menor sombra de dúvidas por me roubarem no dia 21.10.20". Em juízo afirmou: que foi assaltado enquanto estava estacionando o seu veículo, tendo colocado a arma em sua cabeça, levando o carro e celular; que a carteira não levaram porque estava no bolso; que o celular estava no carro; que o veículo é de passeio e utilizava para trabalhar de uber; que ficou uma semana sem o veículo; que tirava cerca de R\$ 250 por noite de trabalho no uber; que foi roubado no início da noite, por volta das 19 ou 20 horas; que o carro foi recuperado sem som, fiação, estepe, ralado etc; que gastou mais de R\$ 5.000,00 para recuperar o carro; que não recuperou o celular iphone de aproximadamente R\$ 2500,00; que na Delegacia fez o reconhecimento por foto dos réus; que confirma que os dois indivíduos que foram apresentados por fotografia que foram os roubadores; que havia um escadão e os réus vieram correndo de lá; que confirma que não fez o reconhecimento pessoal dos réus na Delegacia mas por fotografia; que foram mostradas 2 fotos de cada réu, não sendo apresentada foto de terceiros; que o branco que estava com a arma e o moreno entrou no banco do passageiro; que visualizou o rosto dos réus no assalto, descrevendo-os como: branco, na verdade pardo que estava armado; que o depoente tem 1,70m de altura e este assaltante era um pouco mais alto e o outro moreno, mais escuro que pardo, este era somente um pouco mais alto que o depoente mas mais baixo que o pardo; que ambos estavam com blusa de frio; que não se recorda se estavam com a mesma roupa na foto da delegacia; que reconhece Jeferson como sendo o mais branco (pardo) que estava com a arma na mão, tratando-se do mais baixo; que na delegacia não teve dúvida no reconhecimento dos dois indivíduos por fotografia.

A testemunha DENILSON SOUZA DOS SANTOS foi ouvida na fase policial (fls. 13) e afirmou:Que estava junto com seu parceiro de farda o Sd PM Vitor quando foram acionado pela base da Polícia Militar de Laranjeiras, versando que havia passado um veículo VW/Gol de placa FEK6C75 pelo OCR, na altura do KM 28 da Rodovia SP332, com queixa de roubo, guarnição da VTR M26507, se deslocou até a Rodovia e na altura do

KM 30 desta Rodovia, se deparou com o veículo mencionado acima, onde foi dado ordem de parada, e os mesmos não obedeceram e empreenderam fuga sentido a Cidade de Franco da Rocha, e foi feito acompanhamento e solicitado apoio, no KM 36 da Rodovia, adentraram no Bairro Jd Marcelino, e chegando na Rua Luís Decreci altura do número 360, conseguiu êxito em abordar o veículo, após abordagem do veículo, desceu 2(dois) indivíduos, e foi feito abordagem na busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, onde os indivíduos se identificaram como Wesley Bryan Silva Moura e Leonardo Leite da Silva, onde quem conduzia o veículo era Leonardo Leite da Silva, onde de pronto os 2(dois) indivíduos assumiram o roubo do veículo na noite anterior. Logo foi dado voz de prisão e encaminhado os indivíduos até esta Delegacia de Polícia. COPOM fez contato com a vítima JEFERSON VIEIRA DA SILVA, que compareceram no pátio desta Delegacia e reconheceu os indivíduos sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do roubo de seu veículo. Em juízo afirmou: que estava em patrulhamento perto da Rodovia, quando pela viatura, no km 28, passou veículo gol branco produto de roubo, sendo que, perto do km 30 deparou-se com o veículo, tendo iniciado acompanhamento e sinal de parada, sendo que, empreenderam fuga, sendo que, no km 36 entraram no bairro Jd Marcelino, acompanhando-os por mais 3 km, sendo detidos; que não se recorda quem conduzia o veículo; que o réu de imediato disseram que tinham perdido e confessaram o roubo; que a confissão foi para a equipe do depoente, estando o depoente presente também; que não se recorda deles terem dito porque não pararam na abordagem; que não se recorda de outros itens da vítima em poder dos réus; que na fuga não perderam o veículo de vista; que ambos os réus confessaram o roubo e se o policial se recorda, falaram que os fatos ocorreram em Francisco Morato;

A testemunha FABIO VÍTOR DA SILVA também ouvida na fase policial 14, afirmou: " Que estava junto com seu parceiro de farda o Cb PM Denilson quando foram acionado pela base da Polícia Militar de Laranjeiras, versando que havia passado um veículo VW/Gol de placa FEK6C75 pelo OCR, na altura do KM 28 da Rodovia SP332, com queixa de roubo, guarnição da VTR M26507, se deslocou até o km 30 da Rodovia SP 332, quando se deparou com o veículo VW/Gol branco de placa FEK6C75, quando foi dado ordem de parada, e os mesmos não obedeceram e empreenderam fuga sentido a Cidade de Franco da Rocha, e foi feito acompanhamento e solicitado apoio, que no KM 36 da Rodovia, entraram no Bairro Jd Marcelino, e assim que entraram na Rua Luís Decreci altura do número 360, conseguiu êxito em abordar o veículo, após abordagem do veículo, desceu 2(dois) indivíduos, e foi feito abordagem na busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, onde os indivíduos se identificaram como Wesley Bryan Silva Moura e Leonardo Leite da Silva, onde quem conduzia o veículo era Leonardo Leite da Silva, onde de pronto os 2(dois) indivíduos assumiram o roubo do veículo na noite anterior. Logo foi dado voz de prisão e encaminhado os indivíduos até esta Delegacia de Polícia. COPOM fez contato com a vítima JEFERSON VIEIRA DA SILVA, que compareceram no pátio desta Delegacia e reconheceu os indivíduos sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do roubo de seu veículo. Em juízo afirmou:que houve acompanhamento do veículo irradiado como produto de roubo, sendo que, foi dada voz de parada e iniciaram fuga, mas conseguiram alcança-los e dete-los; que não se recorda qual dos réus conduzia o veículo; que nada de ilícito foi achado no veículo; que ambos os réus confessaram o roubo em data anterior; que é da mesma equipe do Policial Denilson; que não acompanhou o reconhecimento na delegacia, ficando do lado de fora; que confirma seu depoimento da fase policial mas hoje pelo lapso de tempo não consegue se recordar;

O réu LEONARDO LEITE DA SILVA exerceu seu direito de permanecer calado em seu interrogatório na fase de inquérito (fls. 15). Em juízo afirmou: que comprou o veículo gol branco por um aplicativo, mas não se recorda qual seria o app porque faz muito tempo; que a compra ocorreu no mesmo dia da prisão; que o veículo foi entregue na estação de Perus com documento, constando do documento o nome de João; que pagou R\$ 6.000,00 pelo veículo, tendo pegado o dinheiro com o primo Vítor, por empréstimo, sendo que, o depoente pagaria a cada três meses uma parcela que não foi definido o valor; que iria transferir o veículo para o seu pai; que ficou apenas com o número do indivíduo 7827-5337; que conhece Wesley de vista, tendo embarcado em Caieiras e o levaria para a casa. Que não parou o veículo porque não tem

habilitação; que não conhecia os policiais; que nega tenha confessado o roubo; que entregou aos policiais o documento em nome do João, não sabendo porque o documento não foi apreendido; que perguntado pelo Ministério Público em qual data pegou o veículo, respondeu que no dia 17 de outubro; que não se recorda se Wesley pediu para o depoente parar o veículo na abordagem policial; que reperguntado diz que não se recorda muito mas acha que a compra ocorreu dia 17 ou 18 de outubro; que em sede policial o depoente foi apresentado à vítima.

O réu WESLEY BRYAN SILVA MOURA também exerceu seu direito de permanecer calado em seu interrogatório na fase de inquérito (fls. 16). Em juízo afirmou: que confessa o roubo na companhia de Leonardo, bem como a fuga no momento da abordagem policial; que Leonardo visualizou a viatura pelo retrovisor, tendo a viatura dado ordem de parada e luz e começou a acelerar; que ficou com medo e confirma que pediu para Leonardo parar.

Em síntese, o conjunto probatório demonstra os fatos descritos na denúncia e no contexto de toda a prova oral, que determinam a certeza do julgamento.

Não existe qualquer elemento que possa colocar em dúvida as afirmações feitas pela vítima e testemunhas, ouvidas tanto na fase policial quanto em juízo. E, nesses casos, há que se acolher à indicação da vítima e das testemunhas que prestarem depoimentos coesos, como já se decidiu:

“PROVA CRIMINAL – Depoimento da vítima – Admissibilidade – Crime de roubo – Preciosidade na identificação do autor do delito – Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado – Recurso não provido. Conteúdo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre elementos desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e evitar a acusação de inocentes” (TJSP – Ementa no. 32068 – Apelação Criminal n. 186.367-3 – Santo André – 2ª Câmara Criminal – 04.09.95 – v.u.)”.

Apelação Criminal ROUBO QUALIFICADO Conjunto probatório suficiente para a condenação. Reconhecimento efetuado pelas vítimas. Prova testemunhal coesa. Não havendo motivo concreto para infirmar tais provas, de rigor a manutenção da condenação Réu que aderiu ao propósito criminoso do adolescente e participou dos crimes aderindo à conduta do infrator Reprimenda e regime prisional. Adequação Apelo desprovido. (TJ/SP, Apl. Nº 0000085-10.2016.8.26.0621, Rel. Min. RACHID VAZ DE ALMEIDA, Dje. 27/07/2017)

Ainda assim:

ROUBO Autoria. Depoimento de vítima indicando como autor. Validade. Depoimento policial que indica a apreensão de parte da res furtiva. Validade. Só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. A apreensão de parte da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (TJ/SP, Apelação nº 0012756-32.2015.8.26.0320, Rel. Min. LAURO MENS DE MELLO, Dje. 10 de Maio de 2018)

Aponto que tese de defesa do corréu Leonardo Leite da Silva de que o veículo encontrado sob sua posse havia sido adquirido em aplicativo de compra e venda restou isolada frente ao contexto probatório.

A vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, afirmou com riqueza de detalhes que: no dia 21.10.2020,, por volta das 20h30, ao estacionar meu automóvel, uma VW Gol, placas FEK6C75, na Rua Virgílio Martins de Oliveira, altura do número 250, na Cidade de Francisco Morato-SP, fui abordado pelos dois homens que no momento sei se chamarem Leonardo Leite da Silva e Wesley Bryan Silva Moura, tendo eles anunciado o roubo. O homem que no momento reconheço como Leonardo estava armado com um revólver prateado e eles roubaram de mim meu aparelho de telefonia celular,, um Iphone SE IMEI 359222073808120 e também meu carro, um VW VW/Gol de placas FEK6C75, e em seguida se evadiram sentido CSU, bairro Santo Antonio Expedida MSG.

O réu Leonardo, por sua vez, não juntou nos presentes autos nenhuma prova de que de fato tenha adquirido o veículo de outrem, conforme afirmado em Juízo. Neste esteira, não produziu qualquer prova que evidenciasse o sustentado, como seria de rigor.

Como é cediço, a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação,

titular da ação penal e responsável pela "persecutio criminis". Na esteira desse posicionamento, compete ao Ministério Público demonstrar a subtração, seu autor e a utilização de arma pelo agente, servindo como prova a palavra da vítima e de eventuais testemunhas do fato. À defesa cabe produzir prova que desconstitua os elementos coligidos pelo titular da ação penal, apresentando prova de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, abrangendo, nesse caso, a hipótese da prova no sentido de que de fato havia adquirido o veículo de outrem. O réu não juntou ao autos nenhum contrato ou documento que certificasse que havia adquirido o veículo. Sequer apontou com precisão o aplicativo em que havia eventualmente utilizado para a sustentada compra. Não comprovado assim que adquiriu o veículo de outrem, e sendo apreendido com a "res furtiva", não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação. Também neste sentido:

ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPÇÃO. Não configurada. Prova certa quanto a posse de parte dos objetos furtados – inversão do ônus da prova. Ausência de provas nesse sentido. Negativa de autoria e versão apresentada em juízo que não foram comprovadas. Reconhecimento do réu sem sombras de dúvidas. Abalo emocional da vítima não configurado. Testemunha policial que confirma a posse e o reconhecimento Dosimetria da pena. Mantida – Regime fechado – reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15024642220198260077 SP 1502464-22.2019.8.26.0077, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 15/04/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/04/2021)

ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Crime praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas – Vícios eventuais da fase investigativa não maculam a ação penal. Teoria dos frutos da árvore envenenada não aplicável ao inquérito policial. Saneamento com o recebimento da denúncia e produção probatória à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa. Prova ilícita. – Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada – Descabida a desclassificação para o crime de receptação – Condenações mantidas. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Culpabilidade acima da média. Circunstâncias e consequências do crime. Uso de duas causas especiais de aumento sem aplicação na terceira etapa de dosagem. Possibilidade. Maus antecedentes de Ailton e Marcio. Inviável o uso de inquéritos policiais, ações penais em andamento ou condenações por fatos posteriores ao crime sob análise em desfavor de Edinilson e Luiz Carlos. Súmula nº 444 do STJ. Personalidade desvirtuada (ausência de estudo psicossocial específico). Conduta social reprovável e liame com organização criminosa (tatuagens) não demonstradas com elementos técnicos. Coeficientes alterados: 1/2 para Ailton e Marcio e 1/3 para Edinilson e Luiz Carlos – Agravante do artigo 61, II, h, do CP (grave ameaça contra criança). Elevação para Luiz Carlos e Edinilson em 1/6. Reincidência de Marcio e Ailton. Exasperações respectivas de 1/5 e 1/3 – Uma causa especial de aumento aplicada na terceira etapa (concurso de agentes). Elevação em 1/2. Proporcionalidade ao número de agentes envolvidos (superior a dois) que potencializa a lesividade, reduz as chances de reação das vítimas e permite o sucesso da empreitada criminosa. Precedentes – Concurso formal. Três patrimônios atingidos. Acréscimo em 1/5 – Descabida a redução ou isenção da pena pecuniária – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III)– Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei. Sobrestamento que, se aplicável, deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções – Apelos providos em parte para reduzir as penas. (TJ-SP - APR: 00040865720158260238 SP 0004086-57.2015.8.26.0238, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 15/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/06/2021) Ademais, há de se considerar que a confissão do corréu Wesley em Juízo que afirmou: "que confessa o roubo na companhia de Leonardo, bem como a fuga no momento da abordagem policial; que Leonardo visualizou a viatura pelo retrovisor, tendo a

viatura dado ordem de parada e luz e começou a acelerar; que ficou com medo e confirma que pediu para Leonardo parar", não restando assim nenhuma dúvida quanto à participação de ambos os réus, Leonardo e Wesley. Ainda neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. Solidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, estando provado que o acusado agiu em concurso de agentes com o corréu que efetivamente abordou a vítima e, mediante grave ameaça, lhe subtraiu a "res", mantém-se sua condenação pelo delito de roubo majorado, sendo descabido o pleito desclassificatório para o crime de receptação. (TJ-MG - APR: 10024161490255001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 21/02/2018, Data de Publicação: 02/03/2018)

Assim, conforme anteriormente mencionado, há nos autos provas robustas e suficientes para confirmação do decreto prisional dos réus Wesley e Leonardo ao crime de roubo.

É certo, ainda, que os réus agiram com unidade de desígnios e previamente ajustados, o que foi relatado pela vítima, narrando haverem os delinquentes agido em conjunto para praticarem o assalto com eficiência.

Quanto à qualificadora do §2º-A do artigo 157, verifico que, não obstante a arma não ter sido encontrada para a realização de perícia a fim de afirmar a sua potencialidade, certo é que o autor foi categórico ao afirmar na fase policial: "declaro que trabalho como motorista de aplicativo 99, de modo que, no dia 21.10.2020,, por volta das 20h30, ao estacionar meu automóvel, uma VW Gol, placas FEK6C75, na Rua Virgílio Martins de Oliveira, altura do número 250, na Cidade de Francisco Morato-SP, fui abordado pelos dois homens que no momento sei se chamarem Leonardo Leite da Silva e Wesley Bryan Silva Moura, tendo eles anunciado o roubo. O homem que no momento reconheço como Leonardo estava armado com um revólver prateado e eles roubaram de mim meu aparelho de telefonia celular,, um Iphone SE IMEI 359222073808120 e também meu carro, um VW Gol de placas FEK6C75". Em juízo também afirmou: que foi assaltado enquanto estava estacionando o seu veículo, tendo colocado a arma em sua cabeça, levando o carro e celular; que a carteira não levaram porque estava no bolso; que o celular estava no carro."

Está sedimentado na jurisprudência que para a configuração da referida causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, se por outros meios, for comprovada a sua existência. Repita-se, os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, a palavra do ofendido assume particular importância, não havendo porque despreza-la. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado que a palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos, como ocorreu nos presentes autos.

Nesta esteira, tendo a vítima afirmado que os meliantes utilizaram de arma de fogo para executarem a prática do delito de roubo, a majorante do parágrafo 2º, II-A deve ser reconhecida. Também neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (Artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do Código Penal)- RECURSO DEFENSIVO - Absolvição - INADMISSIBILIDADE - Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Desclassificação para o delito de receptação - INVIABILIDADE. Circunstâncias devidamente caracterizadas - A não apreensão da arma não inviabiliza o seu reconhecimento, sendo obtido por meio de outras provas. Restrição da liberdade das vítimas para a prática do delito. Pena-base fixada no mínimo legal e redimensionamento da fração na terceira fase da dosimetria - 1/3 (um terço). Fixação do regime inicial semiaberto - Artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 00247895420168260050 SP 0024789-54.2016.8.26.0050, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 13/11/2019, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/11/2019)

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendido o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (porque não apreendida e não periciada), redução da pena pela confissão e menoridade relativa e fixação de

regime aberto. Descabimento. 1. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de arma. Precedentes. Ainda, o emprego de arma, no crime de roubo, não consiste em vestígio da infração, mas em meio intimidativo, a tornar mais vulnerável a integridade física do sujeito passivo. Assim, mantida a majorante. 2. Pena. Cálculo. Forma equivocada. Readequação necessária. Razoabilidade. Respeito ao princípio da individualização da pena. Redução que se impõe. 3. Menoridade relativa e confissão. Prejudicado. Sentença que já considerou menoridade relativa e confissão, aplicando-as, efetivamente, no cálculo da pena. Pleito prejudicado, por ausência de interesse recursal. 4. Regime aberto. Descabimento. regime inicial fechado que se mostra o mais adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência. Precedentes. Somente a segregação em regime fechado é adequada, "in casu", para que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja, impedir que os indivíduos/penitentes retorne à prática criminosa, considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais fora cometido. Parcial provimento. (TJ-SP - APR: 15000915520218260236 SP 1500091-55.2021.8.26.0236, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/01/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022)

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. Ministério Público. Pretendido reconhecimento também da majorante do emprego de arma de fogo. Cabimento. Embora não apreendida com o réu, a referida arma de fogo usada no roubo, o reconhecimento da causa de aumento relativa à sua existência prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia. Assim, basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de arma para a rendição das vítimas. De outro lado, tal majorante, no crime de roubo, não consiste em vestígio da infração, mas em meio intimidativo, a tornar mais vulnerável a integridade física do sujeito passivo ao fato. Precedentes. Pretendida a redução da pena ao mínimo, por alegar a ocorrência de bis in idem entre as condenações referidas nas primeira e segunda fases da pena. Alternativamente, que seja afastada a agravante da calamidade pública, compensada a reincidência com a confissão, abrandamento do regime prisional, inclusive com aplicação da "detracção". 1. Redução da pena por ocorrência de bis in idem. Inobservado. Embora não explicitadas as condenações utilizadas na primeira e segunda fases da pena, foram citadas as folhas em que estariam elas. Assim, com simples observação a estas, verifica-se diversa a condenação que foi utilizada como antecedente criminal, daquela utilizada para comprovar reincidência. Irregularidade inexistente. Reconhecimentos mantidos. 2. Agravante da "calamidade pública". Propriedade. Devidamente reconhecida, porque o crime em análise foi praticado durante o estado de calamidade pública, reconhecido em razão da pandemia do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 6 de 2020, em vigência desde 20 de março de 2020, bem como Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), o que enseja a aplicação da referida circunstância objetiva. Agente que, de qualquer modo, aproveitou-se de situação de menor vigilância estatal. Assim, deve ser mantida. 3. Compensação da reincidência com a confissão. Inviabilidade. Conforme entendimento, inclusive adotado por esta Câmara, que considera a reincidência, no caso, dupla, uma delas específica, situação que prepondera sobre a confissão aplicando-se o artigo 67 do Código Penal. Aplicação da atenuante, no entanto, vislumbrada, por verificar-se acréscimo menor do percentual mínimo normalmente aplicado. Legitimidade. Sentença, também neste aspecto, mantida. 4. Abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessário, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Situação que torna

inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória. Recurso ministerial provido e recurso defensivo não provido. (TJ-SP - APR: 15158732920218260228 SP 1515873-29.2021.8.26.0228, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 29/04/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022).

Por fim, também restou configurado o crime de desobediência, descrito no artigo 330 do Código Penal.

Afirmou a testemunha DENILSON e FABIO VÍTOR em sede policial que "estava junto com seu parceiro de farda quando foram acionado pela base da Polícia Militar de Laranjeiras, versando que havia passado um veículo VW/Gol de placa FEK6C75 pelo OCR, na altura do KM 28 da Rodovia SP332, com queixa de roubo, guarnição da VTR M26507, se deslocou até a Rodovia e na altura do KM 30 desta Rodovia, se deparou com o veículo mencionado acima, onde foi dado ordem de parada, e os mesmos não obedeceram e empreenderam fuga sentido a Cidade de Franco da Rocha, e foi feito acompanhamento e solicitado apoio, no KM 36 da Rodovia, adentraram no Bairro Jd Marcelino, e chegando na Rua Luís Decreci altura do número 360, conseguiu êxito em abordar o veículo, após abordagem do veículo, desceu 2(dois) indivíduos, e foi feito abordagem na busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, onde os indivíduos se identificaram como Wesley Bryan Silva Moura e Leonardo Leite da Silva, onde quem conduzia o veículo era Leonardo Leite da Silva, onde de pronto os 2(dois) indivíduos assumiram o roubo do veículo na noite anterior. A Testemunha Denilson afirmou em juízo: "que estava em patrulhamento perto da Rodovia, quando pela viatura, no km 28, passou veículo gol branco produto de roubo, sendo que, perto do km 30 deparou-se com o veículo, tendo iniciado acompanhamento e sinal de parada, sendo que, empreenderam fuga, sendo que, no km 36 entraram no bairro Jd Marcelino, acompanhando-os por mais 3 km, sendo detidos". A testemunha Fabio Vítor afirmou em juízo: que houve acompanhamento do veículo irradiado como produto de roubo, sendo que, foi dada voz de parada e iniciaram fuga, mas conseguiram alcançá-los e detê-los; que não se recorda qual dos réus conduzia o veículo".

Há de se ressaltar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem considerado tipificada a desobediência em situações nas quais policiais militares ou rodoviários determinam a parada do veículo por suspeita de conduta ilícita (criminosa) mas não são atendidos pelos motoristas:

"1. É cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais, no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195, do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. 2. Na hipótese dos autos, contudo, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP." (AgRg no REsp 1.805.782/MS, j. 18/09/2019).

Neste sentido, considerando terem os policiais militares confirmado que foram acionados pela base da Polícia Militar de Laranjeiras, versando que havia passado um veículo VW/Gol de placa FEK6C75 pelo OCR, na altura do KM 28 da Rodovia SP332, com queixa de roubo, e que, após ordem de parada empreenderam fuga, restou comprovado o crime de desobediência.

Sustentou o corréu Wesley, outrossim, pela sua absolvição quanto ao crime de desobediência, uma vez que não era ele quem conduzia o veículo no momento da abordagem policial. Todavia, não obstante afirmação do corréu, certo é que encontrava-se em conluio com Leonardo, vez que, conforme confessado na fase policial, o veículo em que estavam era produto de roubo.

Portanto, ainda que tenham os réus negado os fatos, certo é que as próprias circunstâncias, juntamente com as narrativas dos policiais deixam evidente que os

acusados, dias após terem subtraído bens da vítima, mas ainda sob a posse do veículo roubado, puseram-se em fuga mediante a determinação policial de parada, percorrendo por distância superior a 6 km até que foram abordados pelos policiais militares. Neste contexto, não há que se falar em absolvição do corréu Wesley em razão do veículo ser conduzido somente por Leonardo. Em que pese a condução do veículo automotor somente um dos meliantes, Leonardo, a ele aderiu Wesley, tanto é que a perseguição durou por mais de 5 quilômetros de extensão. Assim, forçoso se faz a condenação de ambos. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente circunstanciado - Concurso de Pessoas - Emprego de arma de fogo - Desobediência - Pleito defensivo colimando a absolvição por ambos os delitos - Inadmissibilidade - Réu seguramente reconhecido por uma das vítimas, nas duas oportunidades em que foi ouvida - Policiais que foram ao encalço do acusado e seu comparsa quando conduziam veículo produto de crime - Desobediência da ordem de parada caracterizadora do crime de desobediência - Precedente - Provas seguras para condenação para ambos os crimes que lhe foram imputados na sentença condenatória - Causas de aumento de pena bem caracterizadas - Réu que estava conluiado com seu parceiro para que juntos praticassem roubos - Emprego de arma de fogo descrito de forma categórica por todas as vítimas - Desnecessidade de apreensão do artefato - Dosimetria penal inalterada - Fundamento idôneo para aumento na primeira fase - Coexistências de duas majorantes que autorizam o aumento de 3/8 na terceira fase, ainda mais quando consideradas as circunstâncias concretas do crime - Concurso formal de crimes bem delineado, uma vez que foram subtraídos bens de duas vítimas distintas, cujos patrimônios não se confundem - Crime de desobediência que merece retificação no regime inicial para o semiaberto - Dicção do artigo 33, caput, do Código Penal - Execução primeiro da pena de reclusão - Apelo PARCIALMENTE provido tão somente para fixar o regime semiaberto para a pena de detenção, ainda que na execução se possa proceder à unificação na forma do art. 111 da LEP, mantendo-se, no mais, todos os demais termos da sentença. (TJ-SP - APR: 00216060920188260114 SP 0021606-09.2018.8.26.0114, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 07/08/2020, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020)

Posto isso, praticaram os réus, com emprego de arma, previamente ajustado e agindo em concurso de agente, para proveito em comum, a subtração dos bens descritos na denúncia, bem como desobedeceram ordem legal de funcionário público para assegurar a impunidade de outro crime.

Passo, pois, à dosagem das penas de LEONARDO LEITE DA SILVA (Código Penal, artigos 59 e 68):

1 - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, incisos II, §2º-A, inciso I

A) Pena-base: 4 anos, meses de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada a considerar. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada a considerar. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, conforme verificado às fls. 141/143 (Processo 1011702-38.2021.8.26.0050 e processo 1501534-92.2018.8.26.0544, que tramitou perante a Vara Criminal de Franco da Rocha), razão pela qual aumento a pena em 1/5, resultando em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: O réu possui reincidência específica (processo 010884-76.2019 8.26.0502 que tramitou na 1ª Vara de Francisco Morato), o que autoriza a exasperação da pena em 1/4, resultando em 6 anos, de reclusão, e 15 dias-multa

Este Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a exasperação em 1/4 quando se tratar de réu reincidente específico, como na hipótese em apreço, e, portanto, a pena imposta na segunda etapa da dosimetria não merece reparo.

Precedentes.(HC 389518 SP 2017/0039232-8. T5 - QUINTA TURMA. P. DJe 19/05/2017. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS).

"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO

DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RÉU QUE OSTENTAVA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO À ÉPOCA DOS FATOS SOB APURAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA DE 1/4 PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA AUMENTO SUPERIOR A 1/3 PELA INCIDÊNCIA DA DUAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. SÚMULA/STJ 443. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. " (HC 389518 SP 2017/0039232-8. T5 - QUINTA TURMA. P. DJe 19/05/2017. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS).

Presente ainda a agravante genérica do artigo 61, II, j, razão pela qual aumento a pena em mais 1/6, resultando em 7 anos de reclusão, e 17 dias-multa.

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4a Câmara Criminal, j. 09/03/2021).

C) Causas de aumento e de diminuição: quanto à aplicação das causas de aumento no crime de roubo, os tribunais entendem que, se houver uma causa de aumento, deve ser aumentada em 1/3; havendo duas, em 3/8; três, em 5/12; quatro, em 11/24; cinco ou mais em 1/2. (Ap. Nº 1119107/7/Barueri/TACrim/SP, 11ª Câm. Rel. Juiz Xavier de Aquino, J. 09.11.98); (TACrim/SP, RT 771/614). Quanto a este proceder, entendo que continua aplicável mesmo com as modificações trazidas pelas leis 13.654/2018 e 13.964/2019. O crime em comento se deu com uma causa de aumento, pois praticado mediante concurso de pessoas, razão pela qual aumento em 1/3, resultando a pena de 9 anos, e 4 meses de reclusão, e 22 dias-multa.

Presente, por fim, a causa de aumento do parágrafo 2º-A, I do artigo 147 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em mais 1/3, resultando em 12 anos, 5 meses e 10 dias, e 29 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Roubo - Cálculo da pena - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes - Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP - Cabimento Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabe optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade - e não um dever - ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deve reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida

austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas